

1501481-84.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/04/2022

... 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501481-84.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501481-84.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2178399/2021 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 18829819 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES, 2178399 - DISE- DEL.SEC.MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAMELA SILVA BISPO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

PAMELA SILVA BISPO e WELLINGTON DE AGUIAR SILVA, qualificados nos autos, foram devidamente denunciados pela Justiça Pública e processados como incursos no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 01º de julho de 2021, por volta das 16h14min, na Estrada Municipal Shohei Inui, próximo ao nº 22, Vila Moraes, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de sede de entidade beneficente e social, agindo em concurso de pessoas, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, cerca de: (i) 128,8g (cento e vinte e oito gramas e oito decigramas) da droga cocaína em forma de crack, acondicionada em 502 (quinhentos e duas) porções; (ii) 23,13g (vinte e três gramas e treze decigramas) da droga cocaína em pó, acondicionada em 24 (vinte e quatro) porções; (iii) 556,7g (quinhentos e cinquenta e sete gramas e sete decigramas), da

droga Tetraidrocanabinol-THC (maconha), acondicionada em 119 (cento e dezenove) porções; (iv) 8,39g (oito gramas e trinta e nove decigramas) da droga Tetraidrocanabinol-THC (skunk), acondicionada em 18 (dezoito) porções, sem autorização legal ou regulamentar.

Consta nos autos, que foi encontrada a quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais), em cédulas diversas, e encontradas mais 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) porções de crack, 04 (quatro) porções de cocaína em pó, 80 (oitenta) porções de maconha e 13 (treze) porções de skunk, na busca no imóvel.

Houve prisão em flagrante (fls. 02), convertida em prisão preventiva domiciliar para Pamela e concedido a liberdade provisória para Wellington, consoante r. decisão (fls. 90/95).

A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2021 (fls. 174). Houve aditamento e o respectivo recebimento (fls. 174).

Citados (fls. 187 e 199), apresentaram resposta à acusação (fls. 197).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária (fls. 229/230).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatórios dos réus (fls. 256).

Ao final, manifestaram-se as partes, mediante sistema audiovisual, por meio de alegações finais orais, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal. O Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado Wellington de Aguiar Silva, e a condenação da acusada Pamela Silva Bispo. A Defesa requereu, preliminarmente, a nulidade pelo ingresso na residência, e pela denúncia anônima não constar nos autos, bem como a absolvição dos acusados (fls. 256).

É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Preliminarmente, rejeito a alegação defensiva de nulidade de prova em razão de invasão e domicílio, uma vez que, conforme exaustivamente já analisado pelo e. Superior Tribunal de Justiça "é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses".

Ainda, o STF, responsável pela uniformização da interpretação constitucional, fixou no Tema 280 de sua Repercussão Geral (RE 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05/11/2015, DJe 10/05/2016) a seguinte tese: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

Rejeito, por fim, a alegação defensiva de nulidade de prova em razão de denúncia anônima não constar nos autos, conforme entendimento da Ministra Thereza de Assis Moura, em processo de sua relatoria, que a autoridade policial tem o dever de apurar a veracidade dos fatos. Então, uma vez que a autoridade pode agir de ofício, o anonimato se torna irrelevante se o resultado das diligências efetuadas apontarem justa causa (Resp. 1.096.274)".

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 07/11), documento juntado disque-denúncia (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17), laudo de constatação (fls. 20/23), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 125/127), laudo pericial do objeto (fls. 128/130), guia de depósito judicial (fls. 135), laudo pericial do local (fls. 146/149), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é certa e recai apenas sobre a acusada Pamela.

Em Juízo, as testemunhas de acusação, Fabiano Alves Ramalho e Clovis Ferreira da Costa, policiais civis, em declarações complementares, disseram que receberam denúncia anônima de tráfico com indicação de características físicas de uma moça, pertencente a organização criminoso. Fomos até o local para verificar a veracidade das informações, e vimos a pessoa descrita na denúncia, Pamela, com o acusado Wellington, sentados na calçada. Ao perceberem a viatura, mesmo descaracterizada, entraram para a casa da Pamela, que estava com uma sacola preta nas mãos. Adentramos na residência e no quintal, abordamos Wellington. Tinha também em cima de uma mesa, no quintal, uma sacola preta com drogas. Pamela indicou o armário da cozinha, continha mais entorpecentes. As drogas estavam embaladas da mesma forma. A casa era da Pamela. A viatura estava a uns 30/50m de distância. Eu não os conhecia. A acusada, Pamela Silva Bispo, em seu interrogatório, disse que um dia antes dos fatos, deu uma festa. Alguém colocou droga na cozinha e no quintal. Não sei de quem são. Eu deixo as pessoas fumarem narguilé na minha casa. As crianças não ficam perto.

Wellington de Aguiar Silva, interrogado, disse que estava conversando com Pamela quando os policiais chegaram. Fui abordado ao lado de fora e ouvi quando Pamela falou que as drogas estavam na cozinha. Não vi a sacola no quintal.

A acusação em relação ao acusado Wellington não se comprovou. Com efeito, o réu foi visto pelos policiais sentado na calçada com a ré, que estava segurando uma sacola preta nas mãos, contendo entorpecentes. Além desta conduta, não há mais nada nos autos que o aponte como autor do crime de tráfico de entorpecentes.

Contudo, em relação a ré Pamela, as provas apontam em sentido diverso.

Os policiais civis foram seguros em afirmar que a acusada Pamela foi vista sentada na calçada, segurando nas mãos, uma sacola preta com entorpecentes. Ao entrar na sua casa, indicou mais drogas, guardadas no armário da cozinha.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Dessa forma, o elemento subjetivo do tipo penal, restou plenamente configurado, tendo em vista, a ciência da ré Pamela em relação às drogas. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual.

Ademais, a acusada não apresentou nenhum fato contrário ao afirmado pela acusação, ao revés, sua versão de que alguém teria guardado as drogas em sua casa, sem seu conhecimento, restou isolada.

A quantidade de drogas apreendidas em poder da ré Pamela, não é pequena, cerca de: 128,8g da droga cocaína em forma de crack, acondicionada em 502 porções; 23,13g da droga cocaína em pó, acondicionada em 24 porções; 556,7g da droga TetraidrocanabinoL-THC (maconha), acondicionada em 119 porções; 8,39g da droga TetraidrocanabinoL-THC (skunk), acondicionada em 18 porções, e mantidas em depósitos na casa, mais 465 porções de crack, 04 porções de cocaína em pó, 80 porções de maconha e 13 porções de skunk, além da quantia de R\$ 110,00 (cento e dez reais).

Veja-se, ainda, a variedade de entorpecentes, principalmente a presença de cocaína, droga de alto poder viciante, e de skunk, droga sintética, comumente encontrada em presídios.

A causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, encontra-se devidamente comprovada pelo laudo do local acostado às fls. 146/149. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma. Confira-se:

(...) Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo

pericial. Precedentes (STJ -AgRg no HC: 488403 SP 2019/0003880-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

(...) A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma (STJ -AgRg no HC: 488403 SP 690916(2021/0281672-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que, devido à quantidade e à variedade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei Antidrogas. Contudo, mantenho a pena no mínimo legal, eis que a expressiva quantidade de drogas será utilizada na terceira fase, para afastar a incidência do redutor. Assim, a pena ficará em 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, eis a ausência de atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, incidirá o aumento de 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

No que tange à aplicação da causa especial de redução, na forma do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, entendo pertinente não a reconhecer, tratando de expressiva quantidade de entorpecente, demonstrando que a ré desenvolvia a mercancia com habitualidade.

Consoante decidido pelas instâncias ordinárias, além da quantidade e da variedade de droga apreendida na posse dos agravantes - 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína e 29 (vinte e nove) de maconha -, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, embaladas e organizadas para a comercialização ilegal e entrega a consumo de terceiros, demonstram a dedicação para a prática da atividade ilícita. AgRg no HC 547549/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 29/05/2020.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, conforme alude o artigo 33, do Código Penal, em virtude da quantidade da pena aplicada, bem como para reprovação dos delitos praticados e prevenção, seja genérica ou específica, que impõe regime mais gravoso em seu cumprimento.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em ambos os delitos. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a ré PAMELA SILVA BISPO, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena de 05 anos e 10 meses, de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no mínimo legal.

Julgo IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o WELLINGTON DE AGUIAR SILVA, qualificados nos autos, da imputação que lhe foi feita, e o faço com fundamento no

artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

A acusada Pamela deverá ser recolhida ao regime fechado.

Expeça-se mandado de prisão.

Com efeito, não obstante a alegação de filho menor de 12 anos, que não foi comprovado nos autos, pontuo que os artigos 318, inciso V e 318-A, do Código de Processo Penal não conferem um direito subjetivo automático à genitora. Ora, "o uso do verbo 'poderá', no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria 'dever' do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei. Semelhante interpretação acabaria por gerar uma vedação legal ao emprego da cautela máxima em casos nos quais se mostre ser ela a única hipótese a tutelar, com eficiência, situação de evidente e imperiosa necessidade da prisão. Outrossim, importaria em assegurar a praticamente toda pessoa com prole na idade indicada no texto legal o direito a permanecer sob a cautela alternativa, mesmo se identificada a incontornável urgência da medida extrema" (STJ, HC nº 356.668/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 10/06/2016).

No mesmo sentido: TJSP, HC nº 2089309-42.2016.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Leme Garcia, j. 12/07/2016. O novel artigo 318-A não pode ser interpretado de maneira diversa. Aliás, cabe aqui avaliar a origem da legislação, que não é outra que não o HC coletivo nº 143.641/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018), o qual ressaltava a possibilidade de prisão em CASOS EXCEPCIONAIS. Nesse sentido, como assentou recentemente o STJ (HC nº 457.100/PR, Min. Laurita Vaz, j. 01/08/2018): "no tocante à prisão domiciliar, não está demonstrado que a Paciente é imprescindível aos cuidados de sua filha menor, nem sequer se mostra recomendável a medida pretendida, pois as atividades ilícitas ocorriam dentro da residência da acusada, colocando em risco a preservação do bem-estar da criança". É o caso aqui, em que acusada guardava as drogas dentro de sua residência, além de ter afirmado, perante esta magistrada, em interrogatório, que deixa as pessoas fumar nuguile em casa.

Evidente a situação excepcional: a maternidade não pode garantir salvo conduto à criminalidade. No caso, não está mesmo comprovada a relação de dependência.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 17).

Autorizo, desde já, a destruição dos demais objetos: bolsa, por inexpressividade econômica.

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Atualize-se o histórico de partes com a prolação da presente sentença.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

(i)expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii)nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii)oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo -execução da pena de multa);

(v)arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público

(atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA